

1501602-58.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2216505/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Daniel Mendes Ferreira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

DANIEL MENDES FERREIRA, qualificado a fls. 12, está sendo processado como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501602-58.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001145

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2216505/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Daniel Mendes Ferreira

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

DANIEL MENDES FERREIRA, qualificado a fls. 12, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, no dia 11 de agosto de 2021, por volta das 00h05, na Travessa Novo Horizonte, n.º 177, bairro Canhema, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros, 129 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 106,20 gramas, 98 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 24 gramas e 78 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 192,60 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudo de constatação de fls. 21/23, e laudo de químico toxicológico de fls. 70/72.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 49/51). A defesa inicial está às fls.99/108 juntada por Advogado constituído. A denúncia foi recebida em 24/01/2022 (fls.116) e certificada a notificação e a citação positiva do Réu as fls.94 e 142.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes e interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, discordando da redução da pena, e de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional mais gravoso, sem direito de apelo em liberdade, requerendo por fim a perda do numerário apreendido.

Já a d.Advogada reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com o redutor da pena e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime menos gravoso e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.
Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 24/27, nos laudos de constatação e no definitivo (fls. 21/23 e 70/72), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 09 e 10) que patrulhavam pela Travessa Novo Horizonte, quando avistaram o ora identificado DANIEL MENDES FERREIRA que caminhava e atravessaria a rua, mas ao notar a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo e mudou o seu rumo, razão pela qual o abordaram e verificaram que ele trazia consigo, em sua cintura, dois estojos contendo em seu interior substância semelhante a droga: 78 invólucros de maconha, 129 invólucros de cocaína e 98 invólucros de crack. Em seu bolso havia a quantia de R\$ 409,85.

Sob o crivo do contraditório os policiais Gabriel Borin , Elison Francez , Renato Sebastião reiteraram que estavam em patrulhamento pelo bairro Canhema e ao

adentrarem numa viela, ponto de venda de drogas já conhecido, viram o réu, por eles reconhecido, quem apresentou nervosismo ao perceber suas presenças, e continuou andando. Abordado e feita busca pessoal, com ele, nas vestes, localizaram duas sacolinhas, tipo estojo/pochete, e dentro delas tinham as drogas e dinheiro. Apreenderam maconha, cocaína e crack, em quantidade razoável. Também apreenderam dinheiro, que o réu confessou ser produto da venda de drogas, alegando ter saído da cadeia recentemente, e não ter arrumado emprego, precisava pagar aluguel e viver, e por isso foi traficar, vender drogas. Reconhecem o réu como sendo essa pessoa que foi presa. Foi a primeira vez que o viram na biqueira já conhecida. Pelo horário, meia noite, tinha gente na rua, mas não muitas pessoas, e o réu estava se dirigindo à casa dele, pelo que falou.

A Testemunha de defesa Nailma Souza respondeu que por volta das 23:50 o réu lhe telefonou porque mora na casa de baixo e queria pagar o aluguel. Saiu no portão e ouviu fogos que foram soltados para avisar que a polícia chegou. Um rapaz subiu correndo e soltou algo, uma sacola. Abriu o portão e o policial já estava com o réu. O réu disse ao policial que estava vindo do trabalho naquela hora, e estava com o dinheiro para pagar o aluguel. Dois policiais subiram para a residência do réu, que segundo ele estaria com a porta encostada, porque ali só mora gente de bem, e logo depois desceram, mas com nada na mão. No dia não foi ao DP porque sua mãe disse que não podiam fazer nada por causa de onde estavam. Não conseguiu reconhecer a pessoa que correu. Viu que os policiais encontraram o dinheiro estava com o réu.

A testemunha de defesa Adeilton Santos disse que no dia em que o réu foi preso ele estava em sua casa até umas 23:25 horas, quando o pagou, por um bico que ele fez por quinze dias, fazendo salgados. Pararam de trabalhar por volta das 20:00 horas, foram para sua casa, tomaram café até por volta das 23:30 horas, quando o réu foi embora. Deu quatrocentos reais como pagamento dele, e depois soube que ele tinha sido preso. Quando o réu trabalhou a quinzena com ele, saíam as seis/sete horas da manhã e ficavam até as oito da noite trabalhando. Adiantou o pagamento para ele.

O réu, em solo policial (fl.12) preferiu valer-se do direito de permanecer calado.

Em juízo o acusado alegou que trabalhava fazendo bicos numa fábrica de salgados. Chegou do serviço e ficou na casa do Adeilton até por volta das 23:30 hs. Mandou mensagem para a vizinha porque ia pagar o aluguel. Soltaram fogos e houve uma correria. Foi abordado pelos policiais e ficou nervoso porque estava respondendo por um processo de tráfico e não podia estar na rua após as 22:00 hs. Eles acharam uma bolsa e disse que não era sua, pois estava vindo do trabalho. E o dinheiro que estava em seu bolso era das duas semanas que tinha trabalhado. Perguntaram se entrassem em sua casa iam achar algo, respondeu que não e que podiam subir, tanto que eles não acharam nada. Não entendeu o motivo de ter sido levado preso, acha que porque eles encontraram a bolsa. O dinheiro estava em seu bolso, que tinha acabado de receber. Na frente de sua casa é um ponto de venda de drogas. Mora sozinho em sua casa, pois sua mulher mora na Bahia. Não contou essa versão antes porque não lhe perguntaram nada no DP, senão já tinha dito essa versão aos policiais. Às reperguntas do MP, negou ter confessado o crime aos policiais, e que lhes contou a versão de hoje antes. Ouviu dizer que os policiais estavam forjando muita gente lá no bairro, mas não conhecia os policiais militares, nem os policiais civis.

Logo, os depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, tais como o auto de apreensão e exibição de grande quantidade e diversidade de drogas, inclusive de alto poder lesivo e viciante, além das provas periciais de fls. 21/23 e 70/72, cujos laudos constatarem se tratarem de substâncias entorpecentes.

E ainda o réu tenha trazido negativa de autoria tardia nessa audiência, depois que teve tempo e condições de amadurecer versão mais satisfatória aos interesses da

defesa, não convenceu, dado que, se verdadeira é essa história, o normal e correto seria ele já ter negado os fatos em solo policial, oportunidade em que deveria ter dito que estava voltando da casa do seu chefe/colega de trabalho, quem inclusive teria lhe pago pelo bico que fizera, e que não estava em poder de nada de ilícito. Assim, tenho para mim que essa versão foi arquitetada com as testemunhas para dar um alibi ao réu. Contudo, pouco crível que ele tenha ficado das 20:30 horas até as 23:30 horas tomando um café na casa de seu amigo, até porque ele sabia que não podia estar na rua após as 22 horas, já que condenado por tráfico, cumpria regime aberto. Assim, tenho para mim que o réu e a testemunha Adeilton não ficaram juntos esse tempo todo.

E quanto à narrativa da Sra. Nailma, ela disse que o réu pagaria o aluguel, até porque ele estava, efetivamente, em poder do dinheiro, mas isso se daria por volta da meia noite? E também quanto a versão de que um rapaz correu e que fogos foram lançados a avisar a chegada dos policiais, em contradição com o que o réu disse, que primeiro soltaram fogos e então houve uma correria, mas Nailma não disse que mais de uma pessoa correu, e tudo para explicar que alguém soltou uma sacola, justamente na frente de Nailma, sendo que o rapaz que corria dos policiais podia já ter dispensado a sacola antes ou depois de ter passado pela testemunha. E aqui mais uma vez questiono que se essa versão é verdadeira, o normal e correto, insisto, seria o réu já ter dito isso desde o início aos policiais militares, e aos policiais civis e à autoridade policial. Assim como a testemunha de defesa Nailma já deveria, ao ver os policiais levarem o réu preso, ter dito que ele estava com o dinheiro do aluguel que ela estava no portão esperando para receber, sendo que podia ter ficado dentro da casa dela, que fica em cima da do réu, esperando para receber ali, já que se tratava de meia noite, horário impróprio para tal fim, digase. E essa testemunha, ainda, alega ter visto os policiais encontrando o dinheiro com o réu, até para que esse montante não se perca como produto de crime, mas que não viu as drogas, o que não favoreceria a Defesa, claro. Mas como ela mesma disse não ter visto toda a abordagem, não se tem como afirmar que o réu não estivesse em poder da pochete/estojo que continha as drogas.

Por outro lado, todos os três policiais afirmaram que o réu confessou informalmente estar vendendo drogas para pagar seu aluguel. Tanto que o policial Renato se recordou especificamente da quantidade das drogas provavelmente por ter lido seu depoimento antes de ser ouvido em juízo, o que não é proibido, e o que não desmerece o relato de seus colegas de farda, dado que todos afirmaram que se tratavam de cocaína, crack e maconha, em grande quantidade. O que basta à condenação, ante a ausência de prova robusta e harmônica em sentido contrário.

Como já dito, houve contradições nos relatos das testemunhas de defesa e entre estes e o interrogatório do réu, quem alegou que após os fogos houve uma correria, enquanto sua testemunha disse que primeiro somente um rapaz correu e abandonou uma sacola para os fogos virem depois, o que ocorreu, muito coincidentemente, na sua frente, embora o rapaz percorresse e continuou percorrendo um trajeto, em fuga dos policiais, podendo abandonar a sacola em qualquer outro sítio. Ainda, a testemunha Nailma, para responder a pergunta de como os policiais entraram na casa do réu, ter dito que a porta estava entreaberta, o dia todo, já que ele saiu as oito da manhã e voltava era quase meia, tudo para alegar que os policiais foram até a casa dele e não encontraram nada de ilícito, fato este que o réu tão pouco alegou em solo policial, quando disse que sequer foi ouvido, mas já foi preso, processado e condenado recentemente por tráfico, sabendo que tem o direito de desde já contar sua versão, quando mais em sua defesa, com tantas testemunhas presenciais a virem depor em seu favor, que já deveriam ter constado desde o início. Especialmente a procedência lícita do tão necessitado dinheiro, que ele conseguiu fazendo um bico, à muito custo, para pagar o aluguel, e sequer comentou isso para que a Sra. Nailma, que ele sequer citou que estaria no portão lhe esperando para receber o valor, já pudesse ser paga.

Diante de todo o exposto antes, tem-se que o relato da testemunha Nailton deve ser tido com reservas, por ser contraditório e pouco crível, tanto que o MP irá apurar crime de falso testemunho. E o relato da Sra. Nailma também deve ser relativizado diante das aludidas contradições, sendo ambas as testemunhas interessadas no deslinde do feito em favor do acusado e, portanto, parciais.

E mesmo que outras testemunhas não tenham sido arroladas pelo MP, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. E não há prova de que no DP ninguém tenha querido lhe ouvir. Ou seja, segundo a versão tardia do réu, todos os policiais teriam agido arbitrariamente e mentem para lhe prejudicar, quando sequer se conheciam.

Embora não presenciado atos de venda/traficância de narcótico, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), a apreensão de dinheiro (fl. 64), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim como a quantidade do narcótico apreendido que reputo excessivo (305 invólucros totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, ou seja, em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, valendo-me do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando uma mais justa individualização da pena.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas, até porque o réu não confessou os fatos nem em solo policial e nem em juízo, e ainda negou tê-lo feito informalmente aos policiais, de modo que não pretende contribuir com a busca da verdade real, nem se mostrou arrependido.

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento de pena. E quanto à redução, em se tratando de réu primário, faz jus ao beneplácito legal, mas por outro lado, considerando a natureza dos narcóticos, especialmente o crack e a cocaína de alto poder viciante e degradante do ser humano, somado à alta quantia em dinheiro apreendida (R\$ 409,85 - fl. 64) a indicar vendas efetivamente efetuadas a usuários, disseminando o vício entre eles, além de estar ele cumprindo pena por outro delito de tráfico, e assim comentendo crime análogo, opto pela redução de 1/6, perfazendo a pena final de 05 anos de reclusão mais 500 dias-multa.

Incabível, por insuficiente e ineficaz à reprovação da grave conduta do agente, e até pela quantidade de pena a não permitir, de modo que ausente o requisito objetivo, não se mostrando tão pouco socialmente recomendável a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos prevista no art. 44 do CP.

Fixo o regime prisional fechado, a teor do disposto no artigo 33, do Código Penal, considerando a quantidade da pena, e a preponderância da natureza (crack/cocaína) e da quantidade da droga (excessiva - 305 invólucros), não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar

por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006.

E mais: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional.” (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista os critérios legais objetivos e a falta de atestado de bom comportamento carcerário atualizado. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal dos acusados, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, sem comprovada residência, sem emprego lícito neste distrito da culpa, sendo incongruente soltá-lo, inclusive para a segurança pública e para a conveniência da aplicação da lei penal. Recomende-se-o no cárcere em que está. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC n.º 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC n.º 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC n.º 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC n.º 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra DANIEL MENDES FERREIRA, qualificado a fls. 12, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 500 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Condeno-o ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesps, já que constituiu Advogada particular.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias e em 60 dias as custas, sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Fica desde já autorizada a incineração dos entorpecentes, e a destruição dos objetos (fls.24/27).

Decreto a perda dos valores apreendidos (fls. 24/27 e 64), pois proveniente da venda espúria de drogas.

Oficie-se ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA